

1500231-28.2021.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... MATHEUS, pelo envolvimento com o tráfico de drogas e roubo. Esclareceu que havia dois indivíduos dentro do carro.

A testemunha Antônio Carlos de Souza, policial militar, declarou que na data dos fatos, ele e demais policiais militares em serviço foram informados, via CAD, sobre a ocorrência de um roubo no estacionamento da "Farmácia Drogal", cujos autores teriam tentado subtrair ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga - SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500231-28.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500231-28.2021.8.26.0612

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE GOMES EMILIANO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE GOMES EMILIANO e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II e §2-A, inciso I, bem como ao artigo 329, caput e §2º, ambos do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10.826/03, em concurso material de infrações (artigo 69, do Código Penal), porque no dia 23 de julho de 2021, por volta das 18h19min, no estacionamento da "Farmácia Drogal", situado na Rua Prudente de Moraes, nº 494, nesta cidade e comarca de Taquaritinga, em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, carteira contendo documentos pessoais e o valor de R\$130,00, pertencentes à vítima Nelson Maximiano de Jesus. Consta ainda que, na mesma data, por volta das 18h30min, na Rua Dr. Manoel Fadigas de Souza, nº 106, nesta cidade e comarca de Taquaritinga, em unidade de desígnios,

subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, veículo VW/Fox, avaliado em R\$20.000,00 e uma carteira contendo R\$400,00, pertencentes à vítima Ailton Marchi.

Por fim, consta que, na mesma data e horário, na rotatória da Avenida Heirton Alves Gomes, nesta cidade e comarca de Taquaritinga, opuseram-se à execução de ato legal, mediante disparo de arma de fogo a funcionário competente para executá-lo.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Boletins de ocorrência (fls. 15/19 e 168/181).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante dos réus (fls. 140/145).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2021 (fls. 218/219), os réus foram citados (fls. 240 e 286) e apresentaram resposta à acusação (fls. 314/318 e 355), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 362/363).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas, três testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição dos delitos de resistência e disparo de arma de fogo, bem como pelo afastamento majorante do delito de roubo, por não ter ficado comprovado o emprego de arma de fogo. Requereu, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva. Subsidiariamente, se reconhecido o emprego de arma de fogo por MATHEUS, requereu a absolvição de CARLOS no tocante delitos de resistência e disparo de arma de fogo, bem como o afastamento da majorante do delito de roubo, em razão do emprego de arma de fogo. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação das penas no patamar mínimo. Pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante decorrente da confissão dos acusados. Postulou pela concessão do direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido da ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 15/19 e 168/181), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), autos de entrega (fls. 22 e 23), fotografias (fls. 65/76), auto de avaliação (fls. 185), relatório de investigação (fls. 187/203), laudos periciais (fls. 242/247, 253/260) e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Em sede inquisitiva, o acusado MATHEUS negou as acusações. Alegou que não praticou roubo algum e que foi de Monte Alto até Taquaritinga com seu amigo CARLOS ALBERTO para encontrar "umas meninas". Disse não ser verdade que tenha roubado veículo, que não estava armado e não possui arma de fogo. Sustentou que os policiais militares lhe disseram que tinha mandado de prisão e então, abordaram-lhe e passaram lhe agredir fisicamente com socos e chutes. Afirmou que ficou com vários hematomas.

Em juízo, o réu confessou a prática dos delitos de roubo. Declarou que estava sob o efeito de drogas e bebidas alcoólicas e que viu o 'rapaz' da caminhonete sozinho e tentou abordá-lo. Negou que estivesse armado. Disse que a vítima reagiu e que, com medo, retirou-se do local. Mencionou que na sequência, se deparou com um veículo Fox, parado, e ordenou que a vítima saísse do carro, tendo ela obedecido. Em posse do veículo, dirigiu sentido à Monte Alto. Que nesse momento, deparou-se com uma viatura policial. Afirmou que os policiais descenderam da viatura atirando. Anotou que, com medo de que fosse acertado pelos tiros, acelerou o veículo. Anotou que a cerca de três a quatro quadras para cima, abandonou o carro e entrou em um bairro. Asseverou que nesse bairro, foi detido pelos policiais e que estes o agrediram, desmaiando. Anotou que estava com diversos cortes e que não sabia como eles apareceram. Que os policiais teriam dito para ele confessar o crime, se não o matariam. Após passar pelo UPA, foi levado à delegacia. Relatou que realizou exame balístico e, após, foram para Santa Ernestina. Afirmou que não ameaçou e nem agrediu a vítima, que apenas pediu para que saísse do carro. Anotou que a vítima

começou a gritar e decidiu sair do local. Disse que CARLOS estava com ele no momento dos crimes. Afirmou que nenhum dos dois estava armado. Em sede inquisitiva, o acusado CARLOS ALBERTO, optou por permanecer em silêncio. Em juízo, o acusado confessou a prática dos delitos de roubo. Afirmou que não agrediu a vítima e que tentou tirá-la do veículo. Não tendo conseguido, obtiveram êxito em subtrair o veículo Fox. Afirmou que ao tentar sair da cidade de Taquaritinga, depararam-se com uma viatura policial. Asseverou que os policiais efetuaram vários disparos na direção deles. Confirmou ter participado dos dois roubos. Negou que estivesse com arma de fogo. Disse que apenas pediu o carro à vítima, que ela saiu e se deitou no chão. Anotou que o crime não foi premeditado. Que estavam em uma festa, usaram drogas e bebida alcoólica, e que subtraiu o veículo para ir embora.

As confissões espontâneas dos acusados foram corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A vítima Nelson declarou que na data dos fatos, estava no estacionamento da "Farmácia Drogal", aguardando sua cunhada que havia descido do carro e ingressado no estabelecimento para comprar medicamentos. Disse que permaneceu em sua caminhonete, com os vidros fechados, quando em dado momento, foi surpreendido por um rapaz que abriu a porta do lado do motorista e lhe agarrou pelo braço, tentando lhe retirar do veículo. Afirmou que reagiu e que saiu de costas, pela porta do passageiro, acionou o alarme do carro e entrou na farmácia. Asseverou que o indivíduo realizou um gesto, por baixo da roupa, insinuando estar armado. Aduziu que depois disso, os assaltantes fugiram, levando sua carteira. Esclareceu que no momento da abordagem, enquanto o agente estava tentando tirá-lo da caminhonete, apareceu um comparsa. Anotou que a Polícia Militar foi informada a respeito do ocorrido por algum funcionário da farmácia. Que passado algum tempo, telefonou no 190 indagando sobre o que deveria fazer, quando foi cientificado de que os agentes tinham sido detidos. Mencionou que recuperou sua carteira, que foi devolvida na delegacia. Confirmou que na delegacia reconheceu, com certeza absoluta, os acusados. Segundo o policial, a carteira foi apreendida com os réus. Alegou que reconheceu os réus pelas imagens da câmara de segurança da farmácia. Anotou não ter sofrido prejuízo financeiro. Esclareceu que o fato acarretou um trauma psicológico. Aduziu que não viu nenhuma arma, mas que os réus fizeram gesto por baixo da roupa, afirmando estarem armados. Afirmou que, quando reagiu, um dos agentes disse "você quer morrer, você quer morrer?".

A vítima Ailton declarou que na data dos fatos, estava na casa da sua amiga Vera Lúcia. Disse que permaneceu dentro do carro, conversando com ela, que estava na calçada. Afirmou que, de forma repentina, aproximou-se um rapaz, com a mão dentro da camisa, sinalizando estar armado, que lhe disse para sair do veículo. Asseverou que saiu de dentro do carro e que o assaltante ordenou que ele e Vera Lucia se deitassem na calçada e assim, com medo, fizeram. Na sequência, os indivíduos saíram com o veículo. Esclareceu serem dois agentes. Quanto ao segundo agente, disse que não chegou a ver se estava armado. Afirmou que os vizinhos da sua amiga acionaram a polícia e que, cerca de dez a quinze minutos depois, os policiais passaram pelo local e informaram que o carro havia sido recuperado. Mencionou que, após, foi até a delegacia e reconheceu um dos assaltantes, o de pele mais clara. Afirmou que Vera Lúcia reconheceu os réus. Anotou que recuperou o celular, a carteira e o veículo. Informou que tinha em sua carteira cerca de R\$ 400,00 em dinheiro e que o valor não foi recuperado. Que um dos agentes estava com a mão por dentro da blusa, sinalizando estar armado.

A vítima Vera Lúcia, ouvida na fase extrajudicial, declarou que, na data dos fatos, por volta das 19h00min, estava em sua casa, quando recebeu uma mensagem, pelo celular, de seu amigo Ailton, dizendo que iria passar em sua casa. Disse que, instantes depois, Ailton chegou ao local, conduzindo o veículo dele. Esclareceu que este permaneceu dentro do carro, que ficou na calçada e que, enquanto conversavam, notou que dois rapazes estavam subindo a rua caminhando quando, ao se aproximarem, um deles, de cor branca e que estava com blusa vermelha, chegou junto a Ailton, abriu a porta do carro e começou a puxá-lo, ordenando que saísse. Anotou que esse rapaz estava com a mão embaixo da blusa, sinalizando estar armado e que viu que

havia volume embaixo das vestes do rapaz. Acredita que fosse arma de fogo, apesar de não tê-la visto. Sustentou que Ailton foi colocado para fora do carro e que tiveram que se deitar na calçada. Afirmou que o rapaz de cor branca estava mais exaltado e que ambos ficavam o tempo todo com a mão embaixo da blusa, ameaçando-os, dizendo que estavam armados. Disse que ela e Ailton foram revistados pelos assaltantes, contudo, nada lhe foi subtraído. Afirmou que, em seguida, os agentes entraram no veículo e partiram, e que, na sequência, a polícia militar foi acionada. Informou que uma viatura policial foi até onde estavam e lá, os policiais disseram que outra guarnição tinha localizado o carro subtraído e detido os agentes. Anotou que não foi agredida. Confirmou que, na delegacia, reconheceu com certeza absoluta MATHEUS como sendo o assaltante de cor branca, que trajava blusa vermelha, que estava mais exaltado e que retirou Ailton do carro. Além disso, confirmou ter reconhecido CARLOS ALBERTO como sendo o outro assaltante, moreno, que apoiou o primeiro. Anotou que no interior do veículo havia um telefone celular e a carteira de Ailton, tendo sido tudo recuperado, exceto o dinheiro que havia na carteira dele.

A testemunha Luciana Aparecida Medeiros declarou que estava dirigindo seu veículo, saindo do bairro Manoel Lopes Moreno, sentido bairro Talavasso, quando parou no "balão" localizado em frente a loja de roupas 'D & D'. Anotou que o veículo Fox passou do seu lado e que saiu do veículo porque percebeu que seu vidro tinha sido estourado. Disse que havia algumas pessoas em um bar, sendo que umas disseram que o tiro partiu da viatura policial e outras disseram que havia partido do veículo Fox. Afirmou que entrou em contato com o batalhão da polícia militar e que ao tomar conhecimento da captura dos agentes, estes a comunicaram e solicitaram que comparecesse na delegacia. Mencionou que verificou que se tratava de um veículo Fox somente na delegacia, ao ver o carro no guincho. Esclareceu que no momento dos fatos não conseguiu identificar o veículo que estava sendo perseguido. Disse que ouviu barulho de tiro. Alegou que estava com os vidros fechados e não conseguiu ver quantos ocupantes havia no interior do veículo em fuga. Esclareceu que não viu os réus portando armas. Não chegou a ouvir quantos tiros foram disparados. Anotou não saber de onde veio o tiro que acertou seu veículo.

A testemunha Adilson Donizete dos Santos, policial militar, declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço nesta cidade, em razão do convênio de "atividade delegada" e que, juntamente com os demais policiais, foram informados sobre uma tentativa de furto no estacionamento da "Farmácia Drogal". Disse que, de imediato, ele e seus colegas se dirigiram até a citada farmácia e lá chegando, conversaram com a vítima Nelson, que relatou ter sido abordado por dois rapazes armados, os quais tentaram arrancá-lo a força do veículo para roubá-lo. Aduziu que os indivíduos fizeram menção de estarem armados. Disse ainda que, de acordo com a vítima, os agentes subtraíram a carteira dele, que estava na caminhonete, e acabaram fugindo. Anotou que saíram em diligência e que logo depois receberam nova notícia, dando conta do roubo de um veículo VW/Fox. Mencionou que em diligências, avistaram o veículo VW/Fox, sendo dirigido por MATHEUS. Disse que desembarcou, tentou se aproximar do carro, quando ouviu dois disparos. Anotou que se protegeu e também efetuou alguns disparos. Afirmou que os assaltantes seguiram com o carro e que foram ao encalço deles. Anotou que continuaram acompanhando o veículo, até que este acabou encalhando num desnível da pista. Disse que os dois indivíduos que ocupavam o veículo saíram do carro e seguiram correndo em direção ao bairro Tênis Park. Afirmou que, com o auxílio de vários outros policiais que chegaram com viaturas, foi possível realizar o cerco e efetuar as prisões de MATHEUS e CARLOS ALBERTO. Anotou que MATHEUS tentou pular um muro dotado de concertina e acabou sofrendo ferimentos. Informou que, em poder dos réus, localizaram os pertences das vítimas. Alegou que o motorista do carro em fuga disparou tiros contra ele e a viatura. Asseverou que viu a arma de fogo, mas como estava a certa distância, não soube identificar qual o tipo de arma. Consignou que as duas carteiras das vítimas foram encontradas com os acusados. Disse que as armas não foram encontradas. Anotou que os acusados são bastante conhecidos nos meios policiais, especialmente MATHEUS, pelo envolvimento com o tráfico de drogas e roubo. Esclareceu que havia dois indivíduos dentro do carro.

A testemunha Antônio Carlos de Souza, policial militar, declarou que na data dos fatos, ele e demais policiais militares em serviço foram informados, via CAD, sobre a ocorrência de um roubo no estacionamento da "Farmácia Drogal", cujos autores teriam tentado subtrair uma caminhonete S10 e, não conseguindo, acabaram levando a carteira e pertences da vítima. Anotou que os dois agentes teriam seguido sentido bairro Alvorada. Disse que saíram em diligência e que, logo depois, foram comunicados, sobre outro roubo, ocorrido naquele bairro, praticado também por dois indivíduos com as mesmas características dos agentes do delito anterior. Asseverou que, nesse segundo roubo, os agentes subtraíram um veículo VW/Fox, de cor preta. Anotou que, em diligências pela Avenida Heitor Alves Gomes, cruzamento com Rua Dr. João Jorge, defronte a loja "D& D", avistaram o veículo Fox, momento em que tentaram proceder a abordagem dos ocupantes. Afirmou que estavam em uma "base móvel" e que o Cabo Adilson desembarcou para realizar a abordagem. Disse que estava atrás, na van, e que ao tentar desembarcar, ouviu disparos de arma de fogo, tendo retornado. Disse que o Cabo PM ADILSON noticiou que os agentes haviam efetuado disparos de arma em direção a viatura, conseguindo se evadir daquele local. Anotou que prosseguiram em diligências, tendo o veículo acessado o bairro Lopes Moreno, saindo no Jardim Acapulco. Disse que nesse último bairro, avistaram o veículo encalhado no desnível da pista. Informou que os agentes desembarcaram do veículo e fugiram rumo bairro Tennis Park. Mencionou que ficou preservando a viatura e que o restante da equipe foi atrás dos indivíduos. Aduziu que conseguiram efetuar a detenção dos dois réus e localizaram alguns pertences das vítimas em poder de MATHEUS e outros no veículo. Anotou que os acusados efetuaram três ou quatro disparos de arma de fogo.

A testemunha Wesley Galdino Onorato declarou conhece o réu MATHEUS, pois trabalharam juntos e foram vizinhos. Alegou que desconhece o envolvimento do réu com armas.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação dos acusados no tocante aos delitos de roubo.

Denota-se que após a perseguição policial, foram encontrados, em poder dos dois agentes, a carteira da vítima Nelson, ainda com o dinheiro e documentos, bem como um telefone celular e a carteira da vítima Ailton. Além disso, foi recuperado o veículo da vítima Ailton (fls. 15/19, 20/21, 22 e 23).

De fato, em delitos de natureza patrimonial, a apreensão da res furtiva em poder do acusado impõe-lhe justificativa inequívoca, competindo-lhe provar a origem lícita do produto com ele encontrado, o que não se verifica na espécie vertente.

Nesse sentido:

"[...] Apelante reconhecido pela vítima e que foi surpreendido na posse de parte da res furtiva. Inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante justificar, de modo plausível, a licitude de estar exercendo a posse do produto de crime, ônus do qual não se desincumbiu". (AREsp 1688667. Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Data da Publicação 05/08/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU E DO ADOLESCENTE, LOGO DEPOIS DO ROUBO CONDENAÇÃO MANTIDA Tendo o réu e o adolescente sido surpreendidos e presos em poder dos bens subtraídos, logo depois dos roubos, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Recurso não provido. (TJSP Apelação Criminal nº 0003210-71.2006.8.26.0609. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda j. 15/12.2016).

ROUBO MAJORADO PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DESACOLHIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA PRISÃO NA POSSE DA RES FURTIVA (...) (TJSP - Apelação Criminal nº 0059263-85.2009.8.26.0506, Relator Euvaldo Chaib, 4ª Câmara Criminal, J. 11.12.2015, DJe 17.12.2015).

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos delitos patrimoniais, com o é o caso do furto, inverte-se o ônus da prova desfavoravelmente ao réu se

este é encontrado na posse da res furtiva. O princípio da insignificância não encontra amparo legal para fins de configurar a atipicidade material do crime de furto qualificado, sob pena de se violar inaceitavelmente os princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos" (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0071.05.022851-0/001, Relator: Des.(a) Adilson Lamounier, data do julgamento: 13/07/2010, data da publicação: 28/07/2010) - grifei.

Tal presunção não foi afastada pela Defesa. Ao revés, os acusados confessaram a prática dos dois roubos, justificando que os praticaram sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas.

Observe, ademais, que as vítimas Nelson, Ailton e Vera Lúcia confirmaram que reconheceram os réus em solo policial e ainda, narraram com detalhes a dinâmica dos fatos, que restaram corroboradas pelas demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório.

Outrossim, as imagens trazidas pelo relatório de investigação de fls. 187/203, obtidas pelo circuito de vigilância da "Farmácia Drogal", dão conta do momento exato em que a vítima Nelson foi abordada pelos réus. Pelas imagens é possível visualizar a abordagem realizada pelo acusado MATHEUS, trajando blusa vermelha, tendo este aberto a caminhonete da vítima (fls. 189), que reagiu com chutes (fls. 191), em sua defesa. Na sequência, as imagens indicam a aproximação do comparsa CARLOS, logo atrás (fls. 191).

Ainda, de acordo com o relatório, a fls. 194, a vítima Nelson tenta fechar a porta da caminhonete, porém é impedido pelo acusado MATHEUS, enquanto que o acusado CARLOS permanece atrás daquele. Na imagem de fls. 196, é possível verificar o momento em que a vítima Nelson consegue deixar a caminhonete. Posteriormente, os réus são vistos deixando o local (fl. 199), com os mesmos trajes que foram presos em flagrante (fls. 59/64).

Ademais, enquanto realizavam diligências, após terem sido notificados do crime ocorrido contra a vítima Nelson, os policiais foram informados que os agentes teriam praticado novo roubo, desta vez, em desfavor de Ailton e Vera Lúcia, sendo que, nesta ocasião, os agentes subtraíram um veículo VW/Fox, de cor preta, além da carteira e do celular de Ailton.

Após tomarem conhecimento do segundo crime, os policiais saíram em diligência e avistaram os acusados ocupando o veículo VW/Fox, subtraído da vítima Ailton, instantes antes. Após perseguição policial, os réus apenas pararam o veículo após este encalhar em um desnível na pista. Na sequência, os acusados tentaram empreender fuga à pé, sendo capturados pelos policiais.

Não prospera a alegação do acusado MATHEUS, de que teria sido agredido pelos policiais militares no momento da captura.

De fato, o policial militar Adilson esclareceu que, após desembarcarem do veículo, os acusados seguiram correndo em direção ao Tênis Park e que MATHEUS tentou pular um muro dotado de concertina e acabou caindo e sofrendo os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 30/31 e laudo pericial de fls. 248/249.

Outrossim, o acusado não apresentou qualquer prova de que tenha sido agredido pelos policiais que atenderam a ocorrência.

De outro lado, saliente-se que o fato de os acusados estarem embriagados quando do cometimento dos delitos não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a imputabilidade penal. Isso porque nada há nos autos no sentido de que a suposta embriaguez foi involuntária ou proveniente de caso fortuito.

Nesta esteira, o art. 28, inciso II, do Código Penal, é claro ao dispor que a inimputabilidade penal não é excluída em razão de embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou pelo uso de substâncias de efeitos análogos.

À propósito:

"APELAÇÃO CRIME DE AMEAÇA INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE INOCORRÊNCIA: A embriaguez voluntária, a teor do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade e, sem demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, impossível afastar a responsabilidade penal do réu. (TJSP; Apelação

Criminal 0000851-61.2012.8.26.0279; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/10/2014; Data de Registro: 20/10/2014).
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ESCALADA - INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL E MEDICAMENTOS - EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PELO ALEGADO ACOMETIMENTO DE DISTÚRBIO - INOCORRÊNCIA: A embriaguez voluntária, a teor do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade e, sem demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, incabível afastar a responsabilidade penal do réu. (TJSP; Apelação Criminal 0007037-56.2010.8.26.0575; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/01/2013; Data de Registro: 14/02/2013)

Logo, não há que se falar que os agentes não possuíam conhecimento nem discernimento de suas ações criminosas.

Para mais, confirmo a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP. Há vasto relato nos autos que demonstram a participação dos dois acusados no crime, o que foi corroborado, inclusive, com a confissão dos réus de que estavam juntos durante as práticas delitivas.

Contudo, deixo de reconhecer a causa de aumento, referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

Muito embora seja prescindível a apreensão das armas de fogo para o reconhecimento da majorante, é necessário que existam outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, o que não se verifica no caso em análise.

Com efeito, todas as vítimas afirmaram que acusados sinalizavam portar armas por debaixo das vestimentas, contudo, nenhuma delas viu o objeto em poder dos acusados. De fato, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que o fato de o agente simular ou mentir que está armado, quer verbalmente, quer por meio de gesto, não possibilita o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo, pois o agente, efetivamente, não manuseou qualquer arma.

Nesta esteira, de acordo com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (2020) quando o agente se vale do próprio dedo ou de um instrumento pontiagudo embaixo de suas vestes, dando a impressão de carregar um revólver, embora configurada a grave ameaça, suficiente para a configuração do delito de roubo, não cabe falar na causa de aumento, pois objetivamente inexistiu arma.

Nesse sentido, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Somente em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça procede ao reexame da individualização da sanção penal, notadamente quando flagrante a ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal ou ausente fundamentação. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, para haver a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mostra-se irrelevante a forma em que manifestada a confissão, se integral ou parcial, notadamente quando o juiz a utiliza para fundamentar a condenação, sendo que, in casu, as instâncias ordinárias, apesar de terem reconhecido a confissão de um dos corréus, afastaram a aplicação da atenuante, uma vez não integral aquela. 4. Hipótese em que, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, a reprimenda não pode ser minorada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Súmula 231 desta Corte. 5. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, porém não caracteriza a causa de aumento de pena pelo uso de arma. 6. Havendo as instâncias ordinárias utilizado a simulação da arma de fogo para qualificar o roubo, caracteriza-se o constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a majorante do uso de arma, fixando a pena dos pacientes em 5 anos e 4 meses de

reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (HC 229221 / SP - 2011/0309565-6 - Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 23/06/2015 - Data da Publicação/Fonte DJe 03/08/2015). Negritei.

Vale destacar que as supostas armas não foram localizadas.

Além disso, calha registrar que, segundo o depoimento dos policiais militares, eles vasculharam o local por onde os réus tentaram fugir e não localizaram as armas. As armas também não foram encontradas no veículo conduzido pelos acusados durante a fuga.

Ademais, conforme laudo pericial de fls. 242/247, os exames efetivados nos "residuogramas" dos materiais colhidos das mãos de ambos os réus não detectaram a presença de chumbo, seja na mão direita, seja na mão esquerda, concluindo que "não houve disparo de arma de fogo" (fl. 247).

Assim, ausentes provas robustas que demonstrem o efetivo emprego de arma de fogo durante a prática dos roubos, sendo de rigor afastar a majorante correspondente. Noutra senda, não é o caso de reconhecimento dos pressupostos do crime continuado. Isso porque, em que pese os dois crimes de roubo majorado noticiados serem da mesma espécie, havendo notícias de que foram cometidos em condições semelhantes de tempo e espaço e com alguma semelhança no modo de execução, não restou demonstrado o requisito subjetivo, ou seja, uma ligação concreta, por meio da qual, necessariamente, ficasse demonstrado que os crimes tenham sido praticados um em continuidade do outro.

Assim, não se constatou que tenha havido um plano de ação comum ou um planejamento unitário, de modo a evidenciar que um crime tenha sido continuação do outro.

Ademais, ambos os acusados possuem passagens por diversos outros crimes de natureza patrimonial, sendo assente o entendimento jurisprudencial de que a reiteração criminosa descaracteriza o crime continuado (fls. 267/271 e 280/284).

À propósito, confira-se os precedentes do C. Supremo Tribunal Federal:

"A prática reiterada de crimes contra o patrimônio, indicadora de delinquência habitual ou profissional, impossibilita o reconhecimento de continuidade delitiva para efeito de unificação de penas. Com base nessa orientação, a 1ª Turma, por maioria, denegou habeas corpus em que pretendido novo cálculo de pena pela prática de 2 delitos de roubo qualificado, objetos de condenações diversas. Ressaltou-se que as seguidas ações criminosas descaracterizariam o crime continuado" (STF: HC 109.730/RS, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 02.10.2012, noticiado no Informativo 682). Negritei.

Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado" (STF: RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, j. 18.03.2008). Negritei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM INTERVALO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias. 2. E mesmo que se entenda preenchido o requisito temporal, há a indicação, nos autos, de que o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos de tráfico, o que afasta a aplicação da continuidade

delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1747139 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2018/0141464-8 - Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 13/12/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2019). Negritei.

Nesta senda, conclui-se que ausentes os requisitos subjetivos para o reconhecimento do crime continuado, impondo-se a aplicação cumulativa de penas.

Em última análise, o conjunto probatório não é suficiente para o decreto condenatório quanto ao crime de resistência.

De fato, o crime em discussão se trata de delito formal, consumando-se “ com o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para execução do ato legal ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pouco importando se assim agindo o sujeito vem a impedir a atuação estatal”. Na mesma linha, leciona Rogério Greco que “Consuma-se o delito de resistência com a simples oposição à execução de ato legal, valendo-se o agente do emprego de violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Na hipótese, embora reconhecida a tentativa de fuga, não se demonstrou que os acusados empregaram violência ou grave ameaça contra os agentes policiais, na tentativa de impedir a atuação estatal.

Com efeito, a versão apresentada pelos policiais de que os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura policial não restou devidamente corroborada pelas demais provas colhidas nos autos.

Como já mencionado, nenhuma arma de fogo foi apreendida em poder dos réus. Estes, por sua vez, negaram estar portando armas quando da prática dos crimes. Além disso, o laudo pericial produzido nos autos concluiu que “não houve disparo de arma de fogo” (fl. 247).

Não bastasse, ouvida em audiência, a testemunha Luciana declarou não saber de onde partiram os tiros que danificaram o para-brisas do seu carro, se da viatura policial ou do veículo utilizado pelos réus.

Nesta seara, as provas produzidas não são seguras no tocante à violência ou grave ameaça necessária à caracterização do crime de resistência.

Com efeito, a condenação exige uma certeza absoluta ao analisar todos os detalhes do processo ou, pelo menos, a soma de vários indícios robustos, que indiquem a responsabilidade dos réus.

No caso concreto, não há essa certeza, uma vez que as declarações dos policiais não foram confirmadas pelas provas produzidas sobre o crivo do contraditório.

Diante disso, a absolvição quanto ao crime de resistência é a medida que melhor se amolda ao caso.

Enfim, analisando o conjunto probatório conclui-se que os elementos de convicção carreados aos autos são suficientes para atribuir aos acusados a responsabilidade criminal pela prática do crime de roubo, por duas vezes, circunstanciado pelo concurso de agentes, e não havendo nenhum fato que afaste a antijuridicidade dos atos e a culpabilidade dos réus, não há que se falar em absolvição.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação das penas.

Respeitando o sistema trifásico, elevo em 1/6 a pena base do acusado CARLOS, em razão de ostentar maus antecedentes, conforme certidão de fls. 280/284 (Proc. 0000020-37.2012.8.26.0368, 0001155-84.2012.8.26.0368 e 0002094-64.2012.8.26.0368). Pena base, portanto, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em relação ao réu MATHEUS, ausentes circunstâncias judiciais, a pena base permanece em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, com relação ao réu MATHEUS, embora tenha confessado o crime, prevalece, nos termos do art. 67 do CP, a circunstância agravante da reincidência, conforme certidão acostada às fls. 267/271 (Proc. 0000030-18.2018.8.26.0612, 0000289-81.2016.8.26.0612, 0000576-63.2017.8.26.0368).

Destaco, à propósito, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal acerca do tema: “(...) CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (...) 5. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante,

prevalece sobre a confissão. Precedentes. (...) (RHC 118107, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavaski, DJ 18.02.2014); "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, §2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência 4. Ordem denegada" (HC 111.849/SP, 2ª Turma, Min. Carmen Lúcia DJE 22/10/2012).

Desta forma, a pena do réu MATHEUS deverá ser majorada em 1/4.

De outro lado, reconheço a atenuante da confissão judicial com relação ao acusado CARLOS, retornando a pena ao patamar inicial, porquanto nesta fase não é possível a redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Penas, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão para o réu CARLOS, e em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o réu MATHEUS.

No terceiro estágio, incide a causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, consistente no concurso de pessoas, acarretando majoração das penas em 1/3, elevando-as à 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o réu CARLOS e à 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão para o réu MATHEUS.

Considerando que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes, aplicam-se cumulativamente as penas, de modo que a reprimenda total será de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o réu CARLOS, e 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o réu MATHEUS.

Considerando os maus antecedentes de CARLOS e a reincidência de MATHEUS, e, diante das penas aplicadas, além do caso concreto, roubo praticado em concurso de agentes, o regime que melhor se amolda é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

As penas pecuniárias, utilizados os mesmos critérios das privativas de liberdade, são fixadas em 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, para o réu CARLOS e em 28 (vinte e oito) dias-multa, também no mínimo legal, para o réu MATHEUS.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para:

I) CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA qualificado nos autos, à pena de em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal;

II) CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE GOMES EMILIANO, qualificado nos autos, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal;

III) ABSOLVER os réus MATHEUS HENRIQUE GOMES EMILIANO e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita como incursos no artigo 329, caput e §2º, ambos do Código Penal e artigo 15, da Lei nº 10.826/03, o que faço com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente

réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Pelas circunstâncias do caso concreto e considerando que os réus se encontram presos preventivamente, não se justifica a soltura após a condenação. Nego-lhes, portanto, o apelo em liberdade.

Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram.

Informe-se o julgamento às vítimas (artigo 201, parágrafo segundo, CPP).

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art.15, III da Constituição Federal, para terem os réus suspensos seus direitos políticos; b) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP;

Defiro os benefícios da justiça gratuita aos sentenciados, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros. Anote-se.

P.I.C.

Taquaritinga, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA